



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000775397

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1070175-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S/A, é apelado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por V.U., deram provimento ao recurso. Acórdão com o relator sorteado e declara voto convergente, por outros fundamentos, a 3ª juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.

São Paulo, 22 de setembro de 2021

SPOLADORE DOMINGUEZ

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 12932

Apelação nº 1070175-76.2019.8.26.0053

Comarca: São Paulo

Apelante: BM Empreendimentos e Participações SPE S/A

Apelado: Município de São Paulo

MM.^a Juíza: Liliane Keyko Hioki

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO DE “DECLARAÇÃO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO PASSÍVEL DE TRANSFERÊNCIA”, NOS TERMOS DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (PDE/14) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL nº 16.050/14, DESCONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI MUNICIPAL nº 16.402/16 – O direito de protocolo é conceito de direito urbanístico que garante a ultratividade da lei, sendo, contudo, excepcional e aplicável a hipóteses diversas da tratada nos autos – Direito líquido e certo à “declaração de potencial construtivo passível de transferência” baseada no Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal nº 16.050/2014) – Ilegalidade, no aspecto, da previsão da Lei Municipal nº 16.402/2016 – Segurança concedida – Sentença reformada.

Apelo provido.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por BM Empreendimentos e Participações SPE S/A contra ato do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, alegando violação a direito líquido e certo.

Aduz, para tanto, que em 10/11/2015 (antes, portanto, da entrada em vigor da Lei complementar Municipal nº 16.402/16) requereu, perante a Prefeitura Municipal de São Paulo, a expedição de “Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência” - tendo por objeto a transferência do direito de construir de imóveis onde, por muitos anos, funcionou o Hospital e Maternidade Umberto Primo -, observando-se as regras do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE/14), instituído pela Lei Municipal nº 16.050/14 (Aprova a Política de

Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002). Atendidos os requisitos legais, a autoridade impetrada expediu a “Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência - SMDU/DEUSO 0144/16”, todavia, aplicou a nova lei de parcelamento uso e ocupação do solo (Lei Complementar Municipal nº 16.402/2016). Protocolizou pedido de rerratificação, sob o argumento de que a emissão se deu em desacordo com as regras estabelecidas à época do requerimento administrativo, porém restou indeferido. Argumentou a impetrante que, como o requerimento da Declaração se deu na vigência estrita e exclusiva do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE/14), o marco temporal para o nascimento do direito é a data da vigência da lei que passou a contemplá-lo, ou seja, a Lei Municipal nº 16.050/14, e não a da época da análise técnica e expedição da declaração. Aduz que sofreu prejuízos, porquanto o advento da nova legislação implicou diminuição do potencial construtivo passível de transferência. Pleiteou, assim, a concessão da segurança para obter a “retirratificação da Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência”, expedida de acordo com as regras do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE/14), instituído pela Lei Municipal nº 16.050/14, desconsiderando as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal nº 16.402/2016.

A r. sentença de fls. 894/898, cujo relatório se adota, denegou a segurança.

Apela a impetrante (fls. 912/947), alegando, em resumo, que “*é de rigor a reforma da r. sentença, eis que: (i) - se aplica ao caso o direito de protocolo previsto no artigo 162 da LPUOS/16, na medida em que, por sua natureza declaratória e vinculada, a Declaração aqui tratada se equipara às licenças edilícias em geral; (ii) - se aplica ao caso o direito de protocolo, porque a lei (o PDE/14) crava a data do protocolo do pedido da 'Declaração' como referência para o processo de transferência do potencial construtivo (art. 125, §2º); (iii) - se aplica ao caso o direito de protocolo, na medida em que a própria LPUOS/16 estabelece que apenas as novas Declarações seriam regidas por aquela legislação superveniente; (iv) - o administrado que reúne os requisitos necessários para o pedido de Declaração não pode ser prejudicado pela aplicação da legislação superveniente, quando há omissão e morosidade administrativa*

na apreciação de seu requerimento; e (v) - a Apelante demonstrou a inconstitucionalidade, a ilegalidade, e, portanto, a inaplicabilidade do art. 24 da LPUOS/16 ao caso concreto, na medida em que - hierarquicamente - essa última norma não poderia proceder à derrogação e modificação frontal do Plano Diretor.” Postula “o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. sentença e concedendo-se a Segurança para o fim de se anular a decisão administrativa que indeferiu (em grau recursal) o pedido de retirratificação da 'Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência' objeto da demanda (Declaração SMDU/DEUSO 0144/16), determinando-se a correção do documento para que seus parâmetros estejam em conformidade com as regras do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE/14), instituído pela Lei Municipal nº 16.050/14, desconsideradas as alterações introduzidas pela LPUOS/16.”

Contrarrazões às fls. 976/1003.

Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 1.016).

Eis o breve relato.

Na lição de Hely Lopes Meireles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág. 37).

No caso, restou demonstrado, nos fundamentos da impetração - com a robustez que o pleito exige - o direito líquido e certo invocado.

Insurge-se a impetrante contra ato da impetrada que, para emitir a "Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência", observou as regras da Lei Municipal nº 16.402/16 (Disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo), muito embora o requerimento administrativo tenha sido realizado sob a vigência do Plano Diretor Estratégico (PDE/14), instituído pela Lei Municipal nº 16.050/14 (Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano

Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002).

Para tanto, alega, primeiramente, que deve prevalecer a regra vigente ao tempo do pedido administrativo, assegurando-lhe o “direito de protocolo”, nos termos do artigo 162 da LM nº 16.402/2016; e, depois, porque, no aspecto, a alteração do “fator de incentivo” trazida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (LM nº 16402/2016), deve ser considerada ilegal, por alterar, indevidamente, a disposição do Plano Diretor Estratégico (LM nº 16.050/2014).

No tocante ao primeiro argumento – “direito de protocolo” –, insta salientar que, de fato, o direito de construir não constitui direito irrestrito do proprietário do imóvel, notadamente, considerando-se a função social da propriedade e a competência dos Municípios para execução da política de desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo.

Assim, a transferência do direito de construir, como constou da r. sentença, constitui prerrogativa da Administração Pública. Nesse sentido, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) dispõe:

“Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de:

I - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

II - preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;

III - servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse

social.

§ 1.º A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput.

§ 2.º A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir.”

Note-se, no particular, que a Lei Municipal nº 16.402/2016, aplicada à espécie, não previu norma de transição a ser implementada aos processos administrativos que já estavam em tramitação.

Ainda, o instituto do “direito de protocolo”, que trata de um conceito de direito urbanístico que garante a ultratividade da lei, estabelecendo regras de transição, é, de fato, excepcional, aplicável, segundo a previsão da LM nº 16.402/16, exclusivamente, a processos de licenciamento de obras, edificações e projetos de parcelamento, de modo a se afastar sua aplicação ao caso em análise, como pretendido pela impetrante, que trata, frise-se, de emissão de “declaração de potencial construtivo passível de transferência”.

A respeito, dispõe o artigo 162 da Lei Municipal nº 16.402/16:

“Art. 162. Os processos de licenciamento de obras, edificações e atividades e os projetos de parcelamento do solo, protocolados até a data de publicação desta lei e sem despacho decisório serão apreciados integralmente de acordo com a legislação em vigor à época do protocolo, exceto nos casos de manifestação formal do interessado a qualquer tempo, optando pela análise integral de acordo com suas disposições.

§ 1º Os processos de licenciamento de obras e edificações referidos no 'caput' serão indeferidos:

I - nos casos previstos no Código de Obras e Edificações (COE) e alterações posteriores;

II - se for requerida a modificação da versão do projeto constante do processo em análise na data de promulgação desta lei, nos seguintes termos:

a) alteração de uso, categoria de uso ou subcategoria de uso;

b) acréscimo superior a mais de 5% (cinco por cento) nas áreas computáveis ou não computáveis;

c) alteração em mais de 5% (cinco por cento) na taxa de ocupação.

§ 2º Serão apreciados nos termos do 'caput' os projetos de parcelamento do solo cuja Certidão de Diretrizes já tiver sido emitida pelo órgão municipal competente.

§ 3º Os projetos de parcelamento do solo previstos no parágrafo anterior serão indeferidos quando for requerida alteração em mais de 5% (cinco por cento) do projeto após a vigência desta lei.” (grifou-se)

Destarte, não há que se falar na desconsideração das alterações introduzidas pela nova legislação, Lei Municipal nº 16.402/16, porquanto esta última não previu norma de transição aos processos que se encontravam em trâmite à época da sua entrada em vigor, e, sendo norma de eficácia imediata atingiu situações ainda não consolidadas (declarações requeridas, mas ainda não expedidas) desde sua entrada em vigor, e o pretense "direito de protocolo" deve ser interpretado de modo restrito, como visto.

Confira-se, em caso parelho, julgado deste Tribunal:

“MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter o recálculo do potencial construtivo passível de transferência nos termos do Plano Diretor de 2002 – Inadmissibilidade – Ausência de ato jurídico perfeito e direito adquirido – Não há que se falar em Direito de Protocolo para aplicação do regime jurídico vigente na data da formulação do pedido durante todo o trâmite do procedimento administrativo – Eficácia do direito pleiteado depende da finalização do próprio trâmite burocrático – Aplicação dos parâmetros do Plano Diretor de 2014 com vigência a partir da publicação – Apelação não provida.” (Apelação Cível 1004905-13.2016.8.26.0053, Rel. Des. FERMINO MAGNANI FILHO, 5ª Câmara de Direito Público, j. 09/04/2018)

Prosseguindo na análise, no tocante ao segundo argumento – ilegalidade da previsão da LM nº 16.402/2016, em razão de afrontar o Plano Diretor –, tem-se, como referido no minucioso voto da eminente Desembargadora FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, 3ª Juíza, que o C. Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso Extraordinário nº 607940/DF, com base no voto condutor do Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, j. 29.10.2015, reconheceu que, nos termos do Estatuto das Cidades, o Plano Diretor *“é um instrumento de política urbana, com natureza de norma jurídica de ordem pública, cujo conteúdo deverá sistematizar a existência física, econômica e social da cidade, estabelecendo objetivos gerais a serem perseguidos na sua administração e instituindo normas que limitam as faculdades particulares de disposição inseridas no direito de propriedade em nome do aproveitamento socialmente adequado dos espaços urbanos”*. Ainda, no mesmo julgamento, foi fixada a tese de Repercussão Geral nº 348, com o seguinte teor: *“Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as*

diretrizes fixadas no plano diretor”

Portanto, conclui-se que o Plano Diretor deve ser tratado como a principal norma municipal de política urbana, em especial, no tocante a alguns pontos fundamentais destacados pelo Estatuto das Cidades, sendo possível a edição de outras leis municipais sobre o tema que, porém, necessariamente, deverão observar as regras daquele instrumento legal, podendo, apenas, complementá-lo ou regulamentar seu manejo.

No aspecto, é importante destacar, no Capítulo que trata do Plano Diretor, o quanto disposto no artigo 42 do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001):

“Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo:

I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5º desta Lei;

II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei;

III – sistema de acompanhamento e controle.

No Município de São Paulo, o Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal nº 16.050/2014) tratou expressamente da transferência do direito de construir, nos artigos 122 e seguintes, dispondo sobre o modo de calcular o potencial construtivo passível de transferência, inclusive, trazendo a equação a ser utilizada, em seu artigo 125, que assim dispõe:

“Art. 125- Nos casos de transferência do direito de construir, nos quais

não há a doação do imóvel cedente, previstos nos incisos do art. 124 desta lei, o potencial construtivo passível de transferência será calculado segundo a equação a seguir:

PCpt = Atc x CAbas x Fi, onde:

PCpt – potencial construtivo passível de transferência;

Atc – área do terreno cedente;

CAbas – coeficiente de aproveitamento básico do terreno cedente, vigente na data de referência;

Fi – Fator de incentivo = 1.

§ 1º Na Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, deverá constar no mínimo:

I – o potencial construtivo passível de transferência;

II – a data de referência;

III – valor unitário, valor por 1m2 (um metro quadrado), do terreno cedente de acordo com o Cadastro de Valor de Terreno para fins de Outorga Onerosa, vigente na data de referência;

IV – informação de que o potencial construtivo passível de transferência foi originado sem doação de terreno.

§ 2º Será considerada como data de referência a data do protocolo da solicitação da Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.”
(d.n.)

Este, portanto, o regramento que deve ser observado, inclusive, pela legislação derivada do Plano Diretor.

Entretanto, a Lei Municipal nº 16.402/2016 (que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, de acordo com a [Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico](#) - PDE), ao tratar das Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC), regramdo a emissão das novas declarações de potencial construtivo passível de transferência, acabou alterando o regramento acima transcrito, no tocante ao “fator de incentivo”, ao dispor, em seu artigo 24, o quanto segue:

“Art. 24- Na emissão de novas declarações de potencial construtivo passível de transferência de imóveis enquadrados como ZEPEC, nos termos do art. 125 da [Lei nº 16.050](#), de 31 de julho de 2014 – PDE, serão aplicados os seguintes Fatores de Incentivo (Fi):

I - 1,2 (um inteiro e dois décimos) para imóveis com área de lote de até 500m² (quinhentos metros quadrados);

II - 1,0 (um inteiro) para imóveis com área de lote superior a 500m² (quinhentos metros quadrados) até 2.000m² (dois mil metros quadrados);

III - 0,9 (nove décimos) para imóveis com área de lote superior a 2.000m² (dois mil metros quadrados) até 5.000m² (cinco mil metros quadrados);

IV - 0,7 (sete décimos) para imóveis com área de lote superior a 5.000m² (cinco mil metros quadrados) até 10.000m² (dez mil metros quadrados);

V - 0,5 (cinco décimos) para imóveis com área de lote superior a

10.000m² (dez mil metros quadrados) até 20.000m² (vinte mil metros quadrados);

VI - 0,2 (dois décimos) para imóveis com área de lote superior a 20.000m² (vinte mil metros quadrados) até 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados);

VII - 0,1 (um décimo) para imóveis com área de lote superior a 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados).

§ 1º A transferência do direito de construir originada de qualquer imóvel enquadrado como ZEPEC fica condicionada à recuperação e manutenção dos atributos que geraram o seu enquadramento como ZEPEC.

§ 2º O não atendimento das providências de conservação do imóvel cedente acarretará ao proprietário ou possuidor multa conforme estabelecido no [Quadro 5](#) desta lei.

§ 3º A multa será renovada automaticamente a cada 30 (trinta) dias, até que sejam comunicadas pelo proprietário ou possuidor, por escrito, e aceitas pela Municipalidade as providências relativas à conservação do imóvel cedente.

§ 4º Ato do Executivo regulamentará a aplicação da transferência do direito de construir de imóveis enquadrados como ZEPEC, bem como os órgãos competentes para a análise e deliberação, garantida a manifestação do Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB, quando for o caso.

§ 5º O valor pecuniário correspondente à totalidade do potencial construtivo transferido no período referente aos últimos 12 (doze) meses em relação às transferências do direito de construir sem doação nos termos do art. 124 da [Lei nº 16.050](#), de 31 de julho de 2014 – PDE, não

poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor total arrecadado no FUNDURB no mesmo período, considerando a data do pedido da certidão de transferência de potencial construtivo.

§ 6º Para fins de aplicação do disposto no parágrafo anterior, o Executivo poderá adotar leilão para a emissão de certidões de transferência de potencial construtivo, cujos procedimentos serão estabelecidos em regulamento específico.” (d.n.)

Ora, o Plano Diretor (LM 16.050/2014) não prevê a possibilidade de haver alteração dos fatores daquela equação, usada para o cálculo do potencial construtivo passível de transferência, nem mesmo, para determinadas situações excepcionais. Assim, para tanto, seria necessária a alteração do próprio Plano Diretor.

O conflito do regramento trazido pela LM 16.402/2016 com a regra estipulada pelo artigo 125 do PDE/2014 é flagrante e, no caso, impõe-se a conclusão de que, ao tratar de matéria já regrada pelo Plano Diretor, a nova lei de parcelamento não se amolda à hipótese prevista no Tema de Repercussão Geral nº 348 (“*Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor*”).

Com isso, é forçoso concluir que a Autoridade Impetrada, ao expedir a declaração de potencial construtivo passível de transferência em favor da impetrante, aqui apelante, baseada no regramento trazido pela LM 16.402/2016, cuja ilegalidade é manifesta, como visto acima, feriu direito líquido e certo da impetrante, à expedição do referido documento, nos termos das regras do Plano Diretor Estratégico (LM 16.050/2014).

Diante do exposto, respeitado o entendimento exposto na sentença recorrida, impõe-se o provimento do recurso, concedendo-se a segurança, para que a Autoridade Impetrada providencie a rerratificação da declaração de potencial



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

construtivo passível de transferência, nos termos do PDE/2014, tal qual buscado pela impetrante.

Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional.

Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, concedendo a segurança, como acima constou.

SPOLADORE DOMINGUEZ

Relator

Voto nº 19.635

Apelação nº 1070175-76.2019.8.26.0053

Comarca: São Paulo (2ª. Vara da Fazenda Pública)

Apelante: BM Empreendimentos e Participações Sociedade de
Propósito Específico S/A.

Apelado: Município de São Paulo

Interessado: Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de São
Paulo

MM.^a Juíza: Liliane Keyko Hioki

Ref ao voto n. 12.932 do Exmo. Des. Spoladore Dominguez

VOTO CONVERGENTE

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO DE “DECLARAÇÃO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO PASSÍVEL DE TRANSFERÊNCIA”, NOS TERMOS DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (PDE/14) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL nº 16.050/14, DESCONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI MUNICIPAL nº 16.402/16 – CABIMENTO. IMÓVEL QUE DÁ ORIGEM À DISCUSSÃO ESTÁ LOCALIZADO ONDE ANTIGAMENTE FUNCIONAVA O ANTIGO HOSPITAL MATARAZZO (HUMBERTO I) E NO QUAL SE PRETENDE A CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO COM ATIVIDADES COMERCIAIS, CULTURAIS, HOTELEIRAS, COM MANUTENÇÃO DE PARTES DO IMÓVEL (TOMBADAS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, DENTRE AS QUAIS A CAPELA SANTA LUZIA). Pedido formulado pela empresa impetrante nos termos do PDE/2014 e na vigência de mencionado

plano Diretor. Demora do Município de São Paulo em expedir o documento de potencial construtivo passível de transferência. Tal mora não pode prejudicar o empreendedor, não sendo aplicável ao caso concreto os novos percentuais de transferência de potencial construtivo previstos na Lei Municipal n. 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – LPUOS/2016). Necessidade de observância ao princípio da boa-fé objetiva e dos princípios de atendimento às finalidades da administração, em conjunto com o interesse público e também o privado. Deve-se aplicar, ao caso concreto, a legislação vigente na data do pedido de protocolo, considerando que tal pedido atende aos regramentos da Lei que trata do Plano Diretor Estratégico. Ademais, a Lei nova (Lei Municipal n. 16.402/2016) não pode modificar ou derrogar a Lei que trata do Plano Diretor Estratégico. Pode apenas complementar, suplementar ou regulamentá-lo, nos termos do decidido no RE 607940/DF, de Relatoria do Exmo. Min. Teori Zavascki, julgado em 29.10.2015.

Segurança denegada na origem – R. sentença reformada.

APELO PROVIDO.

Vistos.

Em primeiro lugar, adoto integralmente o Relatório do Exmo. Des. Relator sorteado, Spoladore Dominguez.

“Trata-se de mandado de segurança impetrado por BM Empreendimentos e Participações SPE S/A contra ato do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, alegando violação a direito líquido e certo.

Aduz, para tanto, que em 10/11/2015 (antes, portanto, da

entrada em vigor da Lei complementar Municipal nº 16.402/16) requereu, perante a Prefeitura Municipal de São Paulo, a expedição de “Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência” - tendo por objeto a transferência do direito de construir de imóveis onde, por muitos anos, funcionou o Hospital e Maternidade Umberto Primo -, observando-se as regras do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE/14), instituído pela Lei Municipal nº 16.050/14 (Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002). Atendidos os requisitos legais, a autoridade impetrada expediu a “Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência - SMDU/DEUSO 0144/16”, todavia, aplicou a nova lei de parcelamento uso e ocupação do solo (Lei Complementar Municipal nº 16.402/2016). Protocolizou pedido de rerratificação, sob o argumento de que a emissão se deu em desacordo com as regras estabelecidas à época do requerimento administrativo, porém restou indeferido. Argumentou a impetrante que, como o requerimento da Declaração se deu na vigência estrita e exclusiva do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE/14), o marco temporal para o nascimento do direito é a data da vigência da lei que passou a contemplá-lo, ou seja, a Lei Municipal nº 16.050/14, e não a da época da análise técnica e expedição da declaração. Aduz que sofreu prejuízos, porquanto o advento da nova legislação implicou diminuição

do potencial construtivo passível de transferência. Pleiteou, assim, a concessão da segurança para obter a “retirratificação da Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência”, expedida de acordo com as regras do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE/14), instituído pela Lei Municipal nº 16.050/14, desconsiderando as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal nº 16.402/2016.

A r. sentença de fls. 894/898, cujo relatório se adota, denegou a segurança.

Apela a impetrante (fls. 912/947), alegando, em resumo, que “é de rigor a reforma da r. sentença, eis que: (i) - se aplica ao caso o direito de protocolo previsto no artigo 162 da LPUOS/16, na medida em que, por sua natureza declaratória e vinculada, a Declaração aqui tratada se equipara às licenças edilícias em geral; (ii) - se aplica ao caso o direito de protocolo, porque a lei (o PDE/14) crava a data do protocolo do pedido da 'Declaração' como referência para o processo de transferência do potencial construtivo (art. 125, §2º); (iii) - se aplica ao caso o direito de protocolo, na medida em que a própria LPUOS/16 estabelece que apenas as novas Declarações seriam regidas por aquela legislação superveniente; (iv) - o administrado que reúne os requisitos necessários para o pedido de Declaração não pode ser prejudicado pela aplicação da legislação superveniente, quando há omissão e morosidade administrativa na apreciação de seu requerimento; e (v) - a Apelante

demonstrou a inconstitucionalidade, a ilegalidade, e, portanto, a inaplicabilidade do art. 24 da LPUOS/16 ao caso concreto, na medida em que - hierarquicamente - essa última norma não poderia proceder à derrogação e modificação frontal do Plano Diretor.” Postula “o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. sentença e concedendo-se a Segurança para o fim de se anular a decisão administrativa que indeferiu (em grau recursal) o pedido de retirratificação da 'Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência' objeto da demanda (Declaração SMDU/DEUSO 0144/16), determinando-se a correção do documento para que seus parâmetros estejam em conformidade com as regras do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE/14), instituído pela Lei Municipal nº 16.050/14, desconsideradas as alterações introduzidas pela LPUOS/16.”

Contrarrazões às fls. 976/1003.

Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 1.016).

Passo a apresentar o meu posicionamento sobre o caso, observando que em alguns elementos há divergência quanto ao posicionamento manifestado pelo Exmo. Des. Relator Sorteado (Spoladore Dominguez) e pelo Exmo. Des. 2º. Juiz (Borelli Thomaz), mas no mérito, propriamente dito, a totalidade da turma julgadora decidiu pela concessão da ordem, por este motivo meu voto é convergente, por outros fundamentos (não necessariamente todos os que estão no voto do Exmo. Des. Relator).

Na lição de Hely Lopes Meireles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág. 37).

No caso, entendo que há direito líquido e certo, que foi ferido no caso concreto.

Segundo os elementos dos autos, desde 2011 a empresa impetrante é proprietária do conjunto de imóveis, em que, por muitos anos funcionou o Hospital Umberto Primo e Maternidade, localizados na Alameda Rio Claro, 20, 28 e 190, São Paulo, Capital, cujo valor histórico é oficialmente reconhecido pelo Estado e pela Municipalidade de São Paulo.

Entendo pertinente esclarecer, ainda, que também segundo os elementos dos autos, há notícias de que em 30.07.86, o Condephaat procedeu ao tombamento do Hospital e Maternidade Umberto I (antigo Hospital Matarazzo), através da Resolução SC 29/86. Em seguida, o imóvel foi tomado 'ex-officio' pelo CONPRESP, através da Resolução n. 05/91. Em 18.02.2014, o CONDEPHAAT editou a Resolução SC n. 13/14, que revogou a Resolução SC n. 29/86 e procedeu ao tombamento completo do conjunto do antigo hospital, *'como bem cultural de interesse histórico, arquitetônico, artístico, turístico, paisagístico e ambiental'* (Art. 1º. Da Resolução SC . 13/14). Na sequência, o CONPRESP, EM 22.05.15, publicou a Resolução n. 05/14, que também tombou “o conjunto Edificado do Antigo Hospital” (art. 1º).

Narra a impetrante que tendo em vista estas peculiaridades do imóvel, passou a buscar a transferência do direito de construir deste imóvel, considerando sua localização em ZEPEC – Zona Especial de Preservação Cultural, e o fato de que entendia preencher todos os requisitos do PDE/2014, e que regra de maneira minuciosa o instituto, com conceituações, condições, hipóteses e fórmulas de cálculo para a transferência e utilização do potencial construtivo.

Narra a Impetrante, ainda, que, em 10.11.2015, deflagrou procedimento administrativo 2015.0.299.931/1 (PA/2015) visando obter o reconhecimento do direito à transferência do seu direito de construir e requerendo a emissão da declaração respectiva. E isto é verificado pelo documento de fls. 154.

No presente “mandamus” insurge-se a empresa impetrante contra ato da impetrada que, para emitir a "*Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência*", observou regras da Lei Municipal nº 16.402/16 (que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, de acordo com a Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico - PDE), apesar de o requerimento administrativo ter sido realizado sob a vigência do Plano Diretor Estratégico (PDE/14), instituído pela Lei Municipal nº 16.050/14 (que aprovou a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002).

Sustenta a impetrante que com a emissão da declaração SMDU/DESU 0144/2016 (consoante se verifica do documento de fls. 319/323 e de fls. 327/328), a empresa ora impetrante protocolou pedido de

rerratificação (PA n. 6068.2019/0002429/0 – PA/2019) (consoante documentos de fls. 338/364) indicando que sua emissão se deu em desacordo com as regras estabelecidas ao momento de seu requerimento (no caso, o PDE/14), observando as alterações ilegais trazidas pela LPUOS/2016. Em razão da utilização dos parâmetros estabelecidos, pela LPUOS/16, a declaração SMDU/DEUso 0144/16 deixou de atestar o verdadeiro potencial construtivo passível de transferência, a que faz jus a impetrante, sob sua ótica, mediante a aplicação exclusiva das regras do PDE/14.

Noticia a impetrante que o pedido de rerratificação foi indeferido, mesmo após a apresentação do competente recurso administrativo, ficando mantido o potencial construtivo passível de transferência atestado pela Declaração SMDU/DEuso 0144/16, o que, segundo sua ótica, representa violação ao seu direito líquido e certo. É o que deflui da leitura dos documentos de fls. 708/776.

Afirma, ainda, que com esta atitude da Municipalidade de São Paulo, a declaração de potencial construtivo passível de transferência prevê apenas 5.511,30 m², ao invés de 27.556,48 m², que seriam passíveis de transferência (potencial construtivo passível de transferência), caso tivesse sido aplicada a Lei Municipal 16.050/2014 (Plano Diretor Estratégico – PDE/2014).

Por certo, quando a empresa impetrante tomou a decisão de efetivar obras de reparo (nas áreas objeto de tombamento pelo patrimônio

histórico) e construções em local que ficou fechado por mais de 20 anos, pelo que se verifica dos elementos dos autos e por matérias jornalísticas pertinentes ao imóvel, a empresa impetrante tinha como parâmetro, para realização das atividades empreendedoras, o potencial construtivo existente na época em que foi formalizado o pedido junto à Municipalidade (protocolo do pedido formalizado em 10.11.2015).

Provavelmente, se o potencial construtivo não fosse aquele vigente na época em que protocolado o pedido na esfera administrativa, nem mesmo haveria interesse na realização das obras de restauro e outros empreendimentos no local, que são de expressiva monta e necessitam de realização de complexas obras de manutenção de áreas tombadas pelo patrimônio histórico, em especial a capela existente no local, consoante se verifica dos elementos constantes dos autos e de matérias jornalísticas sobre as obras já realizadas e a serem efetivadas.

Considero que se impõe a revisão da declaração de potencial construtivo passível de transferência, pois a apelante possui direito líquido e certo a que a transferência do potencial construtivo de seus imóveis seja regida pela Lei Municipal n. 16.050, de 31.07.2014 (PDE/2014), sem incidência das regras posteriores, previstas pela Lei Municipal 16.402/16 (LPUOS/2016).

Com efeito, a declaração emitida pela Municipalidade fixou área de potencial construtivo transferível inferior àquela que seria devida (nos termos da Lei que institui o plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - PDE/2014), vigente à época do protocolo do pedido, por parte da empresa impetrante. A declaração acabou sendo emitida pela

Municipalidade com base na Lei Municipal n. 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – LPUOS/16), sendo que as regras destas últimas mudaram as diretrizes do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo de 2014.

O Plano Diretor Estratégico de 2014 (previsto na Lei Municipal 16.050/2014) estabelecia fórmula de cálculo do potencial construtivo passível de transferência para os imóveis localizados em ZEPEC, COM FATOR DE INCENTIVO = 1.

Na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação de Solo instituída na Lei Municipal n. 16.404/2016, houve fatores de incentivo diferenciados para imóveis localizados em ZEPEC (inversamente proporcionais à área do bem).

A r. sentença denegou a segurança, sustentando que não se aplica o direito de protocolo ao caso concreto. Contudo, a solução dada na r. sentença não merece prevalecer, pelos motivos abaixo indicados.

Ao contrário do que foi apontado na r. sentença, reputo que o direito de protocolo previsto na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Municipal n. 16.402/2016) prevê que os processos e projetos protocolados até a data de sua publicação serão apreciados de acordo com a legislação em vigor **à época do protocolo correspondente**.

Com efeito, o art. 162 da Lei Complementar Municipal n. 16.402/2016 prevê que:

“Os processos de licenciamento de obras, edificações e

atividade se os projetos de parcelamento do solo, protocolados até a data de publicação desta lei e sem despacho decisório serão apreciados integralmente de acordo com a legislação em vigor à época do protocolo, exceto nos casos de manifestação formal do interessado a qualquer tempo, optando pela análise integral de acordo com suas disposições.

§ 1º. Os processos de licenciamento de obras e edificações referidos no 'caput' serão indeferidos:

I – nos casos previstos no Código de Obras e Edificações (COE) e alterações posteriores;

II – se for requerida a modificação da versão do projeto constante do processo em análise na data de promulgação desta lei, nos seguintes termos:

Alteração de uso, categoria de uso ou subcategoria de uso;

Acréscimo superior a mais de 5% (cinco por cento) nas áreas computáveis ou não computáveis;

Alteração em mais de 5% (cinco por cento) na taxa de ocupação.

§ 2º. Serão apreciados nos termos do 'caput' os projetos de parcelamento do solo cuja certidão de diretrizes já tiver sido emitida pelo órgão municipal competente.

§ 3º. Os projetos de parcelamento do solo previstos no parágrafo anterior serão indeferidos quando for requerida alteração em mais de 5% (cinco por cento) do projeto após a vigência desta lei.

Respeitado entendimento diverso, reputo que o caput do art. 162 (direito de protocolo) se estende a qualquer procedimento contido na Lei Municipal 16.402/2016, inclusive no que se refere à declaração de potencial construtivo passível de transferência, considerando que, por motivos óbvios, o empreendedor tem a expectativa de poder contar com o potencial construtivo **previsto na época em que formulou o pedido.**

Entendo que esta é a interpretação que melhor se harmoniza com a ideia de direito adquirido, segurança jurídica, boa-fé e lealdade e ainda o da confiança legítima que devem nortear os atos administrativos e os atos que envolvem a administração e o particular nas atividades que envolvem o direito de construir, especialmente no caso concreto, considerando o grande vulto da obra denominada “Cidade Matarazzo” que será implantada no imóvel. Lembre-se que a Transferência de Potencial Construtivo é utilizada pelo particular para que possa arcar com os ônus da preservação do bem tomado. No caso concreto, são notórias as custosíssimas obras de engenharia envolvidas na preservação de vários componentes do imóvel, em especial a Capela Santa Luzia, existente no local, assim como a restauração e preservação do antigo complexo denominado Hospital e Maternidade Humberto Primo (antigo Hospital Matarazzo), assim como a implantação de complexo hoteleiro, gastronômico, cultural e comercial, no quadrilátero, cuja entrada é efetuada pela Alameda Rio Claro, na região da Avenida Paulista. A título de exemplo das obras previstas para serem realizadas, pode-se verificar matéria extraída da internet: acesso em 17.08.2021: <https://veja.abril.com.br/brasil/capela-suspensa-santa-luzia-hospital-matarazzo-umberto-i/>.

Aliás, Celso Antonio Bandeira de Melo destaca, na obra “*Grandes Temas De Direito Administrativo. A Estabilidade Dos Atos Administrativos E A Segurança Jurídica, a Boa-Fé E A Confiança Legítima Antes Os Atos Estatais*”, São Paulo: Malheiros, 1ª. Ed., 2010., p. 177/179, que o:

“princípio da boa-fé, da lealdade e da confiança legítima,

tanto como o da segurança jurídica, têm aplicação em todos os ramos do Direito e são invocáveis perante as condutas estatais em quaisquer das esferas: legislativa, administrativa ou jurisdicional”..... “na órbita do legislativo a pacífica aceitação da irretroatividade das leis tanto como a consagração constitucional da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada garantem a vigência da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção à confiança legítima contra eventuais indevidos descomedimentos que pudessem provir de leis.... Em rigor, o princípio da segurança jurídica, tanto como o da lealdade e boa-fé ou o da proteção à confiança legítima, são da própria essência do direito, e sobretudo do Estado Democrático de Direito, sua vigência é irrefragável. Enquadram-se entre os chamados princípios gerais de direito” (negritei).

Respeitado o posicionamento em contrário, manifestado pelos Exmos. Des. Spoladore Dominguez e Borelli Thomaz, impõe-se aplicar a regra do “direito de protocolo”, ao caso concreto, quanto à expedição da certidão de potencial de construtivo passível de transferência, também em virtude do que prevêm os art. 23 e 30, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que trata da necessidade de que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, regulamentos e outros (LINDB – Decreto Lei n. 4657/42, com a redação dada pela Lei 13.655, de 2018):

“art. 23. a decisão administrativa controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais”

“Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas”.

É certo que tal alteração legislativa não estava em vigor na época em que emitida a declaração discutida nos presentes autos. Entretanto, as regras que foram consubstanciadas nos art. 23 e 30 da LINDB pela Lei 13.655/2018 já se encontravam em nosso ordenamento jurídico, na forma de princípios e decorriam da aplicação da Constituição e da legislação infraconstitucional, que de longa data prezam pela segurança jurídica. Por este motivo, faço referência a tais normas nesta oportunidade.

Justamente levando em conta estes elementos e estes princípios que norteiam a atividade do particular e a necessidade de harmonizar os interesses públicos e os privados, é que a Lei Federal 13.874/2019, que trata da declaração de direitos de liberdade econômica (DDLE), também reúne expressamente direitos que já estavam previstos na Constituição Federal, assim como em legislação esparsa. Embora tal lei seja posterior aos atos discutidos, nos presentes autos, entendo adequado mencionar regras que estão previstas em tal diploma legal, a fim de demonstrar que a legislação nacional caminha cada vez mais para normatizar aquilo que já estava na Constituição Federal e em legislações esparsas como princípios gerais de garantia da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e outros já mencionados acima:

“Art. 1º. Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal.

§ 1º. O disposto nesta lei será observado na aplicação e na

interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho, nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente.

§ 2º. Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas.

“Art. 2º.. São princípios que norteiam o disposto nesta lei:

I – a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas;

II – a boa-fé do particular perante o poder público;

III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas.

IV – o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado.

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre os critérios de aferição para afastamento do inciso IV do caput deste artigo, limitados a questões de má-fé, hipersuficiência ou reincidência”.

Art. 3º. São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do país, observado o disposto no parágrafo único da Constituição Federal:

....

IV – receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário.

IX – ter garantia de que, nas solicitações de atos públicos de

liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei”.

Na esteira de que meu posicionamento, cito, a título de exemplo, julgado no sentido de que o direito de protocolo previsto no art. 162 da Lei 16.402/2016 também se aplica aos processos de outorga onerosa de potencial construtivo:

“Ementa. Agravo de instrumento – ação declaratória – alvará de aprovação de reforma e execução de obras. Decisão que indeferiu a tutela antecipada para determinar que o agravado expeça imediatamente o alvará de aprovação de reforma e o alvará de execução de obras, mediante garantia do Juízo. Pleito de reforma da decisão cabimento – o art. 162, da Lei de Uso e Parcelamento do Solo (Lei Municipal n.16.402, de 22.03.2016), garante o 'direito de protocolo' aos processos de licenciamento de obras, edificações e atividades, bem como aos projetos de parcelamento do solo protocolados, que não tenham despacho decisório até a data da publicação desta nova lei, ao permitir a aplicação da legislação vigente à época do protocolo – o termo 'processo de licenciamento de obra, edificação e atividades' abrange todo o procedimento necessário para a obtenção de autorização para a construção ou reforma de imóveis – necessidade de garantia do juízo – decisão reformada – agravo de instrumento provido..... considerando que o termo 'processo de licenciamento de obra, edificação e atividades' abrange todo o procedimento necessário para a obtenção de autorização para a construção ou reforma de imóveis, o que inclui o cálculo e pagamento do valor devido pela outorga onerosa do potencial construtivo adicional, parece, ao menos em uma análise perfunctória, que o 'direito de protocolo' também atinge o pedido de transferência do potencial construtivo do imóvel tombado, realizado pelo agravante. Deste modo, os critério para o cálculo do valor devido a título de outorga onerosa do potencial construtivo devem

ser aqueles estabelecidos na legislação vigente à época do protocolo, ou seja, a Lei Municipal n. 160.50, de 31.07.2014 e não a Lei de Uso e Parcelamento do Solo (Lei Municipal n. 16.402, de 22.03.2016), como ocorreu” (Agravado de instrumento n. 2251364-37.2016.8.26.000, da Comarca de São Paulo, julgado pela Colenda 3ª. Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 16.05.2017, Relator Exmo. Des. Kleber Leyser de Aquino).

Por sua vez, ao contrário do sustentado na r. sentença, a Lei Municipal n. 16.050, de 31.07.2014 - PDE/2014 (Plano Diretor Estratégico Município de São Paulo), determinou **expressamente a data do protocolo como critério de expedição da declaração**. É o que deflui, segundo minha ótica, da leitura do art. 125:

“Art. 125: Nos casos de transferência do direito de construir, nos quais não há a doação do imóvel cedente, previstos nos incisos do art. 124 desta lei, o potencial construtivo passível de transferência será calculado segundo a equação:

§ 1º. na declaração de potencial construtivo passível de transferência expedida pela secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano deverá constar no mínimo:

.....II – a data de referência....

§ 2º. Será considerada como data de referência a data do protocolo da solicitação da declaração de potencial construtivo passível de transferência à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano” (grifei).

Ora, segundo minha ótica, a data de referência a que faz menção expressa a Lei Municipal 16.050/2014 (PDE) é **aquela do protocolo do pedido junto ao ente municipal pertinente**, motivo pelo qual a legislação aplicável para emissão do documento deve ser aquela vigente à época do protocolo do pedido. Assim, conforme meu

entendimento ao ler os dispositivos legais acima apontados, o legislador incluiu expressamente regra de transição referente à Transferência de Potencial construtivo (TDC).

Por outro lado, a própria LPUOS/2016 dispõe que os “**fatores de incentivo**” nela contidos somente se aplicam às novas declarações, ou seja, às declarações cujos pedidos foram formulados após sua entrada em vigor.

Com efeito, o art. 24 da LPUOS/2016 prevê que:

“art. 24. Na emissão de novas declarações de potencial construtivo passível de transferência de imóveis enquadrados como ZEPC, NOS TERMOS DO ART. 125 DA Lei 16.050, de 31.07.2014 – PDE, serão aplicados os seguintes fatores de incentivo”.

Ora, se os fatores de incentivo criados pela LPUOS/2016 incidem apenas sobre as novas “declarações”, obviamente não se aplicam à situação da apelante, que formulou pedido de protocolo antes da vigência desta última lei municipal.

Ademais, o pedido de certidão possui as características típicas de licenças urbanísticas, o que reforça o direito líquido e certo de observância das regras fixadas no momento do protocolo.

Em se tratando de direito subjetivo intrínseco ao direito de propriedade, o direito de construir apenas pode ser limitado por expressa disposição legal., em virtude do que dispõe o art. 5º., caput, e XXII, 170, II, da CF/88 e art. 5º., II do mesmo diploma legal.

E, em virtude da proteção conferida pelo ordenamento jurídico

ao direito de propriedade, a licença urbanística possui caráter vinculado e os critérios de emissão devem ser objetivamente tipificados em lei formal, não se tratando de juízo discricionário (de conveniência e oportunidade) para sua emissão.

Reputo que a declaração e as licenças construtivas possuem a mesma natureza declaratória e vinculada, típica das licenças urbanísticas.

Celso Antonio Bandeira de Mello esclarece que o direito confere aos administrados uma blindagem, para que as situações iniciadas sob a égide da lei antiga sejam por ela regidas, inclusive no que toca aos seus desdobramentos e direitos conexos:

“A teoria do direito adquirido e seu reconhecimento pela legislação dos povos cultos veio a se constituir na fórmula mais perfeita para a salvaguarda da tranquilidade jurídica e para os interesses dos indivíduos. Através dela construiu-se um mecanismo contra mudanças bruscas, oriundas de alterações legais que teriam o condão de subverter as composições de interesses lisamente constituídos, porque previstos ou autorizados no sistema normativo vigente ao tempo de sua instauração. Sem o amparo do direito adquirido irromperia a álea nas relações sociais, a imprevisibilidade, o sobressalto, noções antiéticas. Aqueles que são os objetivos centrais do próprio direito: a previsibilidade e segurança..... Em suma: o direito adquirido é uma blindagem. É o encasulamento de um direito que segue e seguirá sempre envolucrado pela lei do tempo de sua constituição, de tal sorte que estará, a qualquer época, protegido por aquela mesma lei e por isso infenso a novas disposições legais que poderiam afetá-los.... vale dizer: direito adquirido, por definição, não é apenas o direito à expressão momentânea fugaz, mas abrange todos os desdobramentos que nele se contêm. Sendo evidente que nas relações jurídicas os direitos se conectam, ora como coexistentes, ora como consequentes uns dos outros, de maneira a formar uma totalidade, cuja identidade se perfaz em sua globalidade, é de mister

concluir, ainda com GABBA, que, em linha de princípio: 'as consequências de um direito adquirido devem ser havidas também como direitos adquiridos junto com ele e em virtude dele, quando se possa considera-las como desenvolvimento do conceito do direito em causa ou transformação' (O Direito Adquirido eo Direito Administrativo. In Revista Interesse Público – IP. Ed. Forum, Belo Horizonte, n. 8, n. 38, julho/agosto/2006).

Por sua vez, verifica-se que, no caso concreto, o pedido de expedição do documento denominado “declaração de potencial construtivo passível de transferência” se deu muito tempo antes da vigência da Lei Municipal 16.402/2016 – Lei de Parcelamento, Uso e ocupação do Solo – LPUOS/16. **Ora, não pode a impetrante ser prejudicada pela demora da administração em efetuar a análise de seu pedido.**

Com efeito, a Lei Municipal n. 16.050/2014 - PDE/2014 (que prevê expressamente a data de protocolo como critério de expedição da declaração) passou a ter vigência em 31.07.2014. O pedido de transferência do direito de Construir efetuado pela apelante, é datado de 11.11.2015, com base na Lei, então em vigor, o PDE/2014.

Em 11.02.2016 se esgotou o prazo (de 90 dias, previsto no COE/92 – vigente à época), para a Municipalidade analisar o requerimento formulado pela impetrante (ora apelante).

Tivesse emitido a Municipalidade a certidão dentro do prazo legal (de 90 dias), não haveria necessidade da discussão instalada no presente “mandamus”.

O empreendedor, que efetivou o pedido de declaração de

potencial construtivo passível de transferência (com base no Plano Diretor do Município de São Paulo – PDE/2014) tinha a legítima expectativa de que fosse emitida a certidão de acordo com a legislação vigente à época em que protocolou seu pedido.

Lembre-se que a Lei PUOS/2016 (Lei Municipal 16.402/2016) passou a vigor em 22.03.2016, ou seja, quando havia, até mesmo decorrido o prazo de 90 dias para a Municipalidade emitir a declaração/certidão.

A Certidão/Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência acabou sendo emitida pela Municipalidade somente em 30.06.2016, quando já estava em vigor a Lei da LPUOS/2016. E esta prevê que processos e projetos protocolados até a data de sua publicação serão apreciados integralmente de acordo com a legislação em vigor à época do protocolo correspondente.

De qualquer forma, se a Municipalidade tivesse decidido acerca da emissão de tal declaração nos 90 dias previstos pela legislação vigente à época (Lei Municipal n. 11.228/92, item 4.2), a declaração teria sido emitida em 11.02.2016, ou seja, bem antes da entrada em vigor da Lei LPUOS/16 (22.03/2016).

A empresa ora impetrante (apelante) não pode ser prejudicada pela mora da Municipalidade em analisar o seu pedido de declaração de potencial construtivo passível de Transferência. E a Municipalidade não pode pretender aplicar novos percentuais de potencial de transferência de

construção, para casos protocolados antes da vigência da Lei Municipal LPUOS/2016.

Por fim, a derrogação e modificação do PDE/2014, pela LPUOS/2016, em matéria de transferência de potencial construtivo, **caracterizam ilegalidade**, considerando que as Constituições Federal e do Estado de São Paulo, o Estatuto da Cidade, a Lei Orgânica do Município de São Paulo, o PDE/2014 (Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo) e a própria LPUOS/16 **estabelecem que o PDE têm a premissa de fixar as diretrizes da política urbana, de modo que as demais leis municipais apenas podem complementá-lo ou regulamentá-lo. Entretanto, não podem modificá-lo ou derrogá-lo.**

Com efeito, a Constituição Federal do Estado de São Paulo, em seu art. 181, prevê que a Lei Municipal estabelecerá, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes.

O Estatuto da Cidade dispõe, em seu artigo 35, que a lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente.

A Lei Orgânica do Município, por sua vez, prevê, no art. 135, que para efetivação da política de desenvolvimento urbano, o Município

adotará legislação de ordenamento do uso do solo urbano, compatível com as diretrizes do Plano diretor.

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE – Lei Municipal 16.050, de 31 de julho de 2014) prevê, no art. 3º., que:

“ART. 3º. o Plano Diretor Estratégico orienta o planejamento urbano municipal e seus objetivos, diretrizes e prioridades devem ser respeitados pelos seguintes planos e normas:

“I - plano plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei orçamentária anual e plano de metas;

II – lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, planos regionais das Subprefeituras, planos de Bairros, planos setoriais de políticas urbano-ambientais e demais normas correlatas.

E, ainda, a Lei Municipal 16.050, de 31.07.2014, no capítulo II, que trata da regulação do parcelamento, uso e ocupação do solo e da paisagem urbana, Seção I (que trata das Diretrizes para a revisão da LPUOS), dispõe, em seu artigo 27, que:

“art. 27. De acordo com os objetivos e diretrizes expressos neste PDE para macrozonas, macroáreas e rede de estruturação da transformação urbana, a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo – OPUOS deve ser revista, simplificada e consolidada, segundo as seguintes diretrizes:

I – evitar a dissociação entre a disciplina legal, a realidade urbana e as diretrizes de desenvolvimento urbanos estabelecidas neste PDE;

II – simplificar sua redação para facilitar sua compreensão, aplicação e fiscalização;

III – considerar as condições ambientais, da infraestrutura, circulação e dos serviços urbanos;

IV – estabelecer parâmetros e mecanismos relacionados à drenagem das águas pluviais, que evitar o sobrecarregamento das redes,

alagamentos e enchentes;

V – criar parâmetros de ocupação do solo relacionados a aspectos geológicos, geotécnicos e hidrológicos;

VI – condicionar a implantação de atividades que demandem a utilização de águas subterrâneas ou interferência com o lençol freático em terrenos e glebas localizados em área de ocorrência de maciços de sólo e rocha sujeitos a riscos de colapsos estruturais e subsidência, mapeados na carta geotécnica do Município de São Paulo, à apresentação de estudos geotécnicos e hidrogeológicos que demonstrem a segurança da implantação;

VII – crias mecanismos para proteção da vegetação arbórea significativa;”

VIII

.....

XLVIII – nos bairros tomados pela legislação de bens culturais, serão observadas as restrições das resoluções dos órgãos municipal, estadual e federal de preservação do patrimônio cultural”.

Cumpre lembrar que o Preâmbulo da Lei Municipal LPUOS/2016 (Lei 16.402, de 22 de março de 2016), prevê que mencionada lei “*disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo do Município de São Paulo, de acordo com a Lei 16.050, de 31 de julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico – PDE*”.

E o art. 1º. da LPUOS/2016 (Lei Municipal 16.402/2016) reza que:

“art. 1º. O parcelamento, o uso e a ocupação do solo no território do Município de São Paulo ficam disciplinados pelas disposições desta Lei, de acordo com a Lei 16.050, de 31.07.2014 – PDE e legislação correlata”.

Assim, verifica-se que o Plano Diretor Estratégico (Lei

Municipal n. 16.050, de 31 de julho de 2014) é que tem a finalidade de fixar as diretrizes de política urbana, de modo que a LPUOS/2016 somente pode complementá-la ou regulamentar, não podendo modificar a PDE, nem derogá-la, como já foi indicado acima.

No sentido do indicado no presente voto encontra-se, a título de exemplo, o decidido na ACP n. 9060985-69.2006.8.26.0000, Rel. Des. Samuel Júnior, j. 29.12.2006, pela Colenda 1ª. Câmara Reservada ao Meio Ambiente desta Seção de Direito Público do E. TJSP.

No sentido da solução aqui indicada, encontra-se o julgado pelo Colendo STF nos autos do RE 607.940, em 29.10.2015, pelo Exmo. Des. Teori Zavascki, que possui a seguinte ementa:

“Constitucional. Ordem urbanística. Competências legislativas. Poder normativo municipal. Art. 30, VIII e art. 182, caput da Constituição Federal. Plano Diretor. Diretrizes básicas de ordenamento territorial. Compreensão. 1. A Constituição Federal atribuiu aos municípios com mais de vinte mil habitantes a obrigação de aprovar Plano Diretor, como 'instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana' (art. 182, parágrafo 1º). Além disso, atribuiu a todos os Municípios competência para editar normas destinadas a 'promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano' (art. 30, VIII) e a fixar diretrizes gerais com o objetivo de 'ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes' (art. 182, caput). Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou distrital) sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano Diretor. 2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar Distrital 710/2005, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em

loteamentos fechados, tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada impede que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do que disciplina o Plano Diretor. 3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com repercussão geral no sentido e que 'os Municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor'.

O Poder Municipal, como se viu, pode fixar regras relativas ao direito de construir e às formas de transferência de potencial construtivo, nas regras pertinentes ao plano diretor. Entretanto, não pode o Poder Municipal, em uma LPUOS/2016 modificar os percentuais de declaração de potencial construtivo passível de transferência, que, como se viu acima, não pode modificar as regras do plano diretor (LPDE/2014).

Contudo, insta salientar que, de fato, o direito de construir não constitui direito irrestrito do proprietário do imóvel, notadamente, considerando-se a função social da propriedade e a competência dos Municípios para execução da política de desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo.

Entretanto, é esperado que o Município guarde coerência nas suas decisões relativas ao uso do solo urbano. E aprecie os pedidos formulados pelos particulares, no que diz respeito ao direito de construir, observando as regras vigentes na época em que os pedidos são formulados.

Isto porque os empreendedores fazem as aquisições de imóveis e os projetos construtivos levando em conta o potencial construtivo existente na época em que dão entrada nos pedidos de aprovação dos projetos que realizam.

É certo que a transferência do direito de construir constitui prerrogativa da Administração Pública. Nesse sentido, o Estatuto da Cidade dispõe:

“Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de:

I - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

II - preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;

III - servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

§ 1.º A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput.

§ 2.º A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir.”

E a Lei que trata do plano Diretor no Município de São Paulo (PDE – 2014), é a que deve ser utilizada no caso concreto, pelos motivos acima já indicados.

Por todos os motivos acima apontados, reputo que a impetrante, possui direito líquido e certo à obtenção da declaração de potencial construtivo passível de transferência com base no regime jurídico estabelecido à época do protocolo de seu pedido, qual seja, com base no Plano Diretor estratégico do Município de São Paulo (PDE/2014).

Note-se, no particular, que a Lei Complementar Municipal nº 16.402/2016, aplicada à espécie, não previu expressamente norma de transição a ser implementada aos processos administrativos que já estavam em tramitação. Entretanto, a Lei de Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE/2014) a previu, e deve ser aplicada pelos motivos acima já indicados (é o Plano Diretor Estratégico do Município que prevê os ditames e as condutas a serem realizadas pelo Município, e pelos munícipes, **não podendo** a Lei de Uso e Parcelamento do Solo - LPUOS/16 restringir direitos, de modo a derrogar ou modificar o Plano Diretor Estratégico do Município).

Por fim, não é possível deixar de aplicar as regras do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (Lei - PDE/2014) apenas porque o art. 162 da Lei Municipal nº 16.402/16 não trata expressamente sobre emissão de declaração de potencial construtivo passível de transferência. Como já indicado neste voto, prevê o art.

“Art. 162. Os processos de licenciamento de obras, edificações e atividades e os projetos de parcelamento do solo, protocolados até a data de publicação desta lei e sem despacho decisório serão apreciados integralmente de acordo com a legislação em vigor à época do protocolo, exceto nos

casos de manifestação formal do interessado a qualquer tempo, optando pela análise integral de acordo com suas disposições.

§ 1º Os processos de licenciamento de obras e edificações referidos no 'caput' serão indeferidos:

I - nos casos previstos no Código de Obras e Edificações (COE) e alterações posteriores;

II - se for requerida a modificação da versão do projeto constante do processo em análise na data de promulgação desta lei, nos seguintes termos:

a) alteração de uso, categoria de uso ou subcategoria de uso;

b) acréscimo superior a mais de 5% (cinco por cento) nas áreas computáveis ou não computáveis;

c) alteração em mais de 5% (cinco por cento) na taxa de ocupação.

§ 2º Serão apreciados nos termos do 'caput' os projetos de parcelamento do solo cuja Certidão de Diretrizes já tiver sido emitida pelo órgão municipal competente.

§ 3º Os projetos de parcelamento do solo previstos no parágrafo anterior serão indeferidos quando for requerida alteração em mais de 5% (cinco por cento) do projeto após a vigência desta lei.” (grifou-se)

Como visto, se há omissão no art. 162 sobre o assunto, a matéria é tratada em outros artigos da LPUOS/2016, bem como há necessidade de aplicação da PDE/2014 no caso concreto, pelos motivos exhaustivamente apontados no presente voto.

Diante do apresentado, reputo que há direito líquido e certo da impetrante à pretendida rerratificação da “Declaração de Potencial



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Construtivo Passível de Transferência”, de acordo com as regras do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE/14), instituído pela Lei Municipal nº 16.050/14, desconsiderando, em consequência, as alterações introduzidas pela nova legislação, Lei Complementar Municipal nº 16.402/16.

Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional.

Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).

Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou, para CONCEDER A SEGURANÇA.

FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

3ª. Juíza



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	14	Acórdãos Eletrônicos	JULIO CESAR SPOLADORE DOMINGUEZ	16FAFA93
15	44	Declarações de Votos	FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA	17059D6A

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 1070175-76.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.